

次の【事例】に関する後記アからオまでの各【記述】を判例の立場に従って検討し、正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。

【事例】

甲（女性、16歳）は、高校の同級生A（女性、16歳）が非行グループと交際し、飲酒喫煙を繰り返していることを知り、それらのAの具体的行動を、特に口止めもせずと同級生2名に告げたところ、同人らを介して、Aの同行動がクラスの全生徒30名の知るところとなった。甲のせいで自己の行状に関するうわさが広まったことを知ったAは、甲を呼び出して暴行を加えた。そのことを知った甲の兄乙は、Aに報復しようと考え、ある日の深夜、A宅付近に自己の車を停め、Aを待ち伏せていたところ、Aの姉B（20歳）がA宅に入ろうとするのを見て、BをAと誤信し、Bを無理やり同車のトランクに押し込んで数キロメートル走行した上、郊外の廃工場に連行した。乙は、上記廃工場において、Bの顔面を数発殴打するとともに、はさみを使ってBの頭髪を10センチメートル程度切断した。乙は、Bが泣き出したのを見て満足し、その場から立ち去ることにしたが、その際、Bのバッグの中から財布を抜き取り、これを持ち去った。乙は、上記財布内にB名義の運転免許証やキャッシュカードが入っていたため、BをAと間違えたことに気付いたが、同カードを不正に使用し、Bの預金で乙の友人Cへの借金を返済しようと考えた。乙は、コンビニエンスストアの現金自動預払機に同カードを挿入し、暗証番号としてBの誕生日を入力したところ、取引ができる状態になったので、その場で、同現金自動預払機を操作し、B名義口座から直接C名義口座へ50万円を送金した。その後、甲の交際相手丙は、乙が警察に逮捕されるのではないかと不安に思った甲からの依頼に応じ、乙の上記一連の犯行について、乙の身代わり犯人として警察に出頭した。

【記述】

- ア. 甲が、Aの上記行動を同級生2名に告げた行為は、特定かつ少数の者にAの名誉を毀損する事実を摘示したにすぎないことから、名誉毀損罪が成立することはない。
- イ. 乙が、Bを無理やり自己の車のトランクに押し込み、上記廃工場に連行した行為は、Bを16歳の未成年者と誤信していたのであるから、生命身体加害目的略取罪ではなく未成年者略取罪が成立する。
- ウ. 乙が、はさみを使ってBの頭髪を切断した行為は、人の生理的機能を損なうものではないから、傷害罪は成立せず暴行罪が成立するとどまる。
- エ. 乙が、B名義口座から直接C名義口座へ50万円を送金した行為は、実質的には預金の占有を移転させる行為であるから、窃盗罪が成立する。
- オ. 丙が乙の身代わり犯人として警察に出頭した行為は、犯人の特定を誤らせることを通じて間接的に犯人の身柄確保を妨げるものにすぎないから、犯人隠避罪は成立せず、証偽偽造罪が成立する。

|         |      |     |     |     |     |     |     |
|---------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| No.442  | 総合事例 |     |     |     |     |     | 正答率 |
| 共通R4-20 | 正解   | ア 2 | イ 2 | ウ 1 | エ 2 | オ 2 | 40% |

## ア 誤っている

本記述は、特定かつ少数の者に名誉を毀損する事実を摘示したにすぎない場合、名誉毀損罪が成立することはないとしている点で、誤っている。

最判昭34.5.7（百選Ⅱ19事件）。名誉毀損罪は「公然」と事実を摘示することを成立要件としている（230条1項）。この点、判例は、「公然」とは、摘示された事実を不特定又は多数人が認識し得る状態を指すとしている（大判昭3.12.13）が、摘示の直接の相手方が特定かつ少数の場合であっても、その相手方を通じて事実が不特定又は多数人へ伝播する可能性があれば「公然」の要件を満たすとしている（伝播性の理論、最判昭34.5.7）。本記述では、甲は、Aが非行グループと交際し、飲酒喫煙を繰り返しているという具体的行動を、特に口止めもせずに同級生2名に告げたと、同人らを介して、Aの同行動がクラスの全生徒30名の知るところとなっている。甲が直接に事実を摘示したのは特定かつ少数であるとしても、不特定又は多数人へ伝播する可能性があったといえる。よって、「公然」に当たる。したがって、甲の行為には、名誉毀損罪が成立することはある。

## イ 誤っている

本記述は、乙に生命身体加害目的略取罪ではなく、未成年者略取罪が成立するとしている点で、誤っている。

生命身体加害目的略取罪（225条）の「略取」とは、暴行又は脅迫を手段として、他人の意思に反して、その生活環境から離脱させ、自己又は第三者の事実的支配の下に置く行為をいう。乙は、Bを無理やり自己の車のトランクに押し込み、A宅から数キロメートル離れた郊外の廃工場に連行しており、同行為は、暴行を手段として、Bの意思に反して、その生活環境から離脱させ、自己の事実的支配の下に置いたといえ、「略取」に該当する。よって、同罪の客観的構成要件に該当する。また、判例（大判明44.12.8）によれば、未成年者を225条所定の目的をもって略取誘拐した場合は単一の本条の罪が成立するとされていることから、乙が20歳のBを16歳の未成年者Aと誤信したとしても、報復しようと考えていた（「生命又は身体に対する加害の目的」）以上、錯誤はない。よって、同罪の故意が認められる。したがって、乙の行為には、未成年者略取罪ではなく、生命身体加害目的略取罪が成立する。

## ウ 正しい

大判明45.6.20により、本記述は正しい。

判例は、傷害罪（204条）の「傷害」とは人の生理的機能の障害と解し、人の毛髪の手切りは傷害ではなく、暴行であるとしている。したがって、甲の行為には、暴行罪（208条）が成立する。

## エ 誤っている ★

本記述は、乙に窃盗罪が成立するとしている点で、誤っている。

窃盗罪（235条）の実行行為である「窃取」とは、財物の占有者（事実上の支配者・管理者）の意思に反してその物を自己または第三者の占有下に移すことをいい、ここでの「占有」は、財物に対する事実的支配をいう。本件において、Bの預金（現実の金銭）に対する事実的支配を有するのは銀行であり、B名義口座から直接C名義口座へ500万円を送金したとしても、銀行からCに財物の占有が移転したとはいえない。よって、乙の行為は「窃取」に当たらない。したがって、乙には、窃盗罪は成立しない。なお、乙は、人を欺いていないため詐欺罪（246条）は成立しないが、電子計算機使用詐欺罪（246条の2）は成立し得る。

## オ 誤っている

本記述は、丙には、犯人隠避罪が成立しないとしている点で、誤っている。

最決平元5.1（百選Ⅱ122事件）。判例は、犯人が逮捕勾留された後、他の者を教唆して身代り犯人として警察署に出頭させ、自己が犯人である旨の虚偽の陳述をさせた事案において、犯人隠避教唆罪（103条、61条1項）の成立を認めている。その理由として、判例は、103条は、捜査、審判及び刑の執行等広義における刑事司法の作用を妨害する者を処罰しようとする趣旨の規定であって、同条にいう「罪を犯した者」には、犯人として逮捕勾留されている者も含まれ、かかる者をして現になされている身柄の拘束を免れさせるような性質の行為も同条にいう「隠避」に当たるということを挙げている。本記述の乙は、生命身体加害目的略取罪、暴行罪、電子計算機使用詐欺罪など「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」に当たる。そして、丙が乙の身代わり犯人として警察に出頭した行為は、「隠避」に当たる。したがって、丙には犯人隠避罪が成立する。

